

1500275-15.2019.8.26.0613

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... os agentes.

A este respeito:

Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. Preliminar.

Inépcia denúncia. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Tráfico de drogas.

Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para os tipos penais previstos nos artigos 28 e 37 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Causa de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

2ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500275-15.2019.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500275-15.2019.8.26.0613

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 413/19/200 - DEL.SEC.CASA BRANCA,
70/2019 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Casa Branca

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CLAUDIA PEREIRA VIEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

JOÃO VITOR DE ALMEIDA e ANA CLÁUDIA PEREIRA VIEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia:

1 - Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde o início deste ano de 2019, nesta Penitenciária "Joaquim de Sylos Cintra", localizada nesta cidade e Comarca de Casa Branca, JOÃO VITOR DE ALMEIDA, preso na penitenciária local, matrícula n. 1.112.350, qualificado a fls. 108/111, e ANA CLAUDIA PEREIRA VIEIRA, qualificada a fls. 12/14, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 2 - Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de junho de 2019, no período da manhã, na Penitenciária "Joaquim de Sylos Cintra", localizada neste município e Comarca de

Casa Branca, JOÃO VITOR DE ALMEIDA, qualificado a fls. 108/111, e ANA CLAUDIA PEREIRA VIEIRA, qualificada a fls. 12/14, em unidade de desígnios e acordo de vontades entre si, traziam consigo e ocultavam, para entrega a consumo de terceiros, cerca de 98 g (noventa e oito gramas) de "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha", e 100 (cem) unidades da droga conhecida como "LSD", substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 07/08, laudo de constatação provisória a fls. 09/10 e procedimento apuratório de falta disciplinar do sentenciado a fls. 63/107). Segundo se apurou, o denunciando JOÃO VITOR estava preso em cumprimento de pena na Penitenciária "Joaquim de Sylos Cintra", aqui situada (matricula nº 1.112.350), e, visando introduzir drogas no interior do referido estabelecimento prisional, com o intuito de entregá-la dentro da penitenciária a consumo de outros presos, associou-se à denuncianda ANA CLAUDIA e ambos combinaram que ela levaria a droga a ele no dia legal da visita. Assim combinado, aproveitando da visita que realizaria ao denunciando JOÃO VITOR, ANA CLAUDIA escondeu as drogas maconha e LSD acima mencionadas na sua cavidade vaginal, a fim de entregá-la no interior da penitenciária ao denunciando JOÃO VITOR, que entregaria a droga para consumo dos demais presos. Quando ingressou no estabelecimento prisional, foi a denuncianda submetida a revista pelo escaneador "boby scanner", utilizado para o acesso ao raio prisional, onde se constatou algum objeto na cavidade vaginal da denuncianda. Conduzida até uma sala reservada, a denuncianda confessou o delito e retirou espontaneamente da vagina as referidas drogas, que seriam destinadas ao denunciando, para posterior entrega a consumo de demais presos. Vale dizer que o local da apreensão, a quantidade, a natureza e acondicionamento da droga, e as circunstâncias da prisão demonstram o fim de mercancia, de modo a caracterizar o crime de tráfico descrito nos artigos 33 da Lei 11.343/06.

Realizada audiência de custódia no dia 23/06/2019, foi concedida à autuada a liberdade provisória nos termos da decisão de fls. 26/33.

Os acusados foram citados pessoalmente (fls. 227 e 236).

Resposta à acusação apresentada as fls. 247/248.

Durante a fase instrutória, foram inquiridas três testemunhas de acusação e interrogados os acusados ao final.

A i. Representante do Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a nobre Defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Por fim, pleiteou a observação da primariedade e da confissão da acusada (fls. 371/372).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo apura a materialidade e autoria dos episódios criminosos narrados na denúncia, condutas tipificadas nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, tendo sido respeitados todos os preceitos constitucionais e legais. Analisando-se a pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que o pedido formulado na presente ação penal é procedente em parte.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, não há provas suficientes para a condenação. Isso porque a prisão decorreu de flagrante, não tendo havido acompanhamento da atividade no tempo.

Com efeito, inexistente comprovação da existência de vínculo associativo estável e permanente, não sendo suficiente para caracterização a apreensão de grande quantidade de drogas. Não consta dos autos elementos sobre a organização do grupo, sobre a divisão de funções entre seus membros, sobre eventual relação de hierarquia entre eles tampouco acerca da mínima estruturação entre os agentes.

A este respeito:

Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. Preliminar.

Inépcia denúncia. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para os tipos penais previstos nos artigos 28 e 37 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 caracterizada. Condenações mantidas. Associação para o tráfico. Ausência de provas do vínculo associativo. Absolvição decretada. Dosimetria. Reajuste do incremento das basílares em 1/5. Multirreincidência do réu Wesley. Incidência do inciso III do art. 40 da Lei de regência. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Réu Wesley multirreincidente e dedicação de Diego a atividades criminosas. Regime inicial fechado mantido. Inviabilidade da redução da pena de multa. Fixação observados os parâmetros estabelecidos pelo tipo penal. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1502786-74.2019.8.26.0616; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/09/2021; Data de Registro: 11/09/2021) Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico - Recursos defensivos e ministerial - Matéria preliminar rejeitada - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento apenas do tráfico - Absolvição - Descabimento - Impossibilidade de condenação, no que se refere ao delito autônomo de associação para o tráfico, pela inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes do imputado vínculo estável e permanente entre os agentes - Dosimetria redimensionada, pelo reconhecimento de circunstância agravante, cuja natureza é objetiva - Pena de Jefferson recrudescida, também, em razão do necessário acolhimento de circunstâncias judiciais negativas, a teor do artigo 42, da Lei Antidrogas - Reprimenda do réu Kleber majorada pelo afastamento do privilégio legal, diante do desfavorecimento das circunstâncias concretamente aferidas, que evidenciam dedicação à mercancia ilícita - Regime prisional de Kleber recrudescido, a fim de guardar proporcionalidade com as peculiaridades delitivas - Sentença reformada nessa extensão - Recursos defensivos desprovidos e insurgência ministerial parcialmente acolhida. (TJSP; Apelação Criminal 1501413-38.2020.8.26.0530; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021)

Impõe-se, portanto, a absolvição por falta de provas.

Diversamente, em relação ao tráfico de drogas, a materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/04), do boletim de ocorrência (fls. 05/06), do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), do auto de constatação provisória (fls. 09/10), da cópia do procedimento apuratório de falta disciplinar (fls. 63/107), do relatório final (fls. 121/122), dos laudos de exame químico-toxicológicos (fls. 134/136 e 169/179) e dos depoimentos carregados aos autos.

A autoria também é certa e recai sobre as pessoas dos acusados.

A testemunha Ana Cláudia Alves, agente de segurança do presídio local, narrou que recebeu informações do diretor de segurança sobre a existência de denúncias no sentido de que a visitante Ana Cláudia tentaria ingressar no presídio com drogas para entregar ao amásio João Vítor para fins de traficância; no dia dos fatos, ao passar pelo scanner corporal, observou uma imagem inconclusiva no corpo da acusada, especificamente no canal vaginal; acionou seu chefe; em seguida, a acusada foi conduzida para uma sala reservada; houve uma discussão, porque a acusada estava muito nervosa; depois de um certo tempo, a acusada confessou que trazia as drogas em seu corpo e retirou a embalagem da vagina; Ana Cláudia confessou que as drogas seriam entregues ao preso João Vítor, a pedido dele; Ana Cláudia foi incluída do rol de visitas do preso em maio; acredita que seria a sétima visita ao preso; a acusada sempre foi revistada nas outras visitas que promoveu ao acusado.

Rogério Rezende Ribas de Ávila Filho, agente penitenciário, contou que, no dia dos fatos, era o diretor do setor de portaria; a agente Marisa detectou uma imagem estranha no scanner corporal da acusada; também avaliou a imagem e também achou estranha; a acusada foi levada para uma sala reservada para conversar com as funcionárias; em dado momento, a acusada ficou um pouco nervosa, retrucou com as

agentes, mas acabou confessando que trazia as drogas no corpo; esclareceu que a acusada agrediu a agente Marisa com palavras de baixo calão; o diretor de segurança do presídio o alertou sobre as denúncias de tráfico de drogas que recaíam sobre a pessoa do preso João Vitor.

O diretor de segurança e disciplina da penitenciária, Fabio Gizzi de Marque, disse que não presenciou os fatos; destacou que tinha denúncias de que a acusada Ana Cláudia levaria drogas para o amásio João Vitor no dia da visita para fins de traficância; na ocasião, durante a passagem pelo scanner corporal, os funcionários responsáveis pelo setor de portaria, constataram uma imagem suspeita no corpo da acusada; indagada, Ana Cláudia confessou que portava drogas em seu corpo; a acusada visitou o acusado na unidade poucas vezes; as denúncias foram anônimas; todas as visitantes passam pelo scanner.

A acusada Ana Cláudia Pereira Vieira na fase administrativa, relatou que é companheira de João Vitor de Almeida, recolhido no presídio de Casa Branca por condenação pelo delito de roubo; na data dos fatos veio para Casa Branca visitar seu companheiro; confessou que tentou ingressar com os entorpecentes apreendidos em sua genitália; pretendia entregar as drogas para seu companheiro; é a primeira vez que transportou drogas; na visita anterior, seu companheiro lhe pediu para trazer as drogas para ele vender no interior do presídio; comprou as drogas de uma mulher, cujo nome não se recorda, em Sorocaba/SP pelo valor de quinhentos reais (fls. 04). Em Juízo disse que na data dos fatos foi visitar seu companheiro no presídio local; passou pelo scanner por várias vezes; a funcionária da portaria pediu para esperar; pediu para ir ao banheiro fazer xixi; a funcionária Marisa lhe pediu que urinasse num balde na frente dela; em seguida, referida funcionária tentou lhe agredir; empurrou a funcionária Marisa; confessou para a funcionária Ana Cláudia que trazia drogas em seu corpo; não agrediu a agente penitenciária em momento algum; não conhecia as agentes penitenciárias antes dos fatos; mora em Sorocaba/SP com seu pai; tem dois filhos menores de idade; não trabalha; estudou até a oitava série; as drogas seriam entregues ao seu companheiro; foi a primeira vez que levou as drogas. O acusado João Vitor de Almeida na fase de inquérito, relatou que realmente solicitou que sua esposa lhe trouxesse as drogas; alega que os entorpecentes eram destinados ao seu próprio consumo (fls. 96). Em Juízo disse que pediu para que Ana Cláudia levasse as drogas; inicialmente sua esposa se negou, mas insistiu e a convenceu; está preso há um ano e oito meses; sua companheira promovia visitas em outras unidades prisionais; mora em Sorocaba/SP; tem um filho e um enteado menores de idade; possui outras condenações; trabalha como autônomo; estudou até a sexta série; pretendia usar a maconha e vender o LSD.

Realmente, a despeito das versões apresentadas pelos acusados, dos depoimentos trazidos aos autos e dos elementos de provas carreados, retira-se que Ana Cláudia Pereira Vieira trazia consigo e ocultava, cerca de 98 g (noventa e oito gramas) de maconha e 100 (cem) unidades da droga conhecida como "LSD", a fim de entregar ao corréu João Vitor de Almeida, atendendo ao pedido deste, que iria revender as substâncias aos demais reeducandos.

Das provas carreadas aos autos, reputo devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas imputado aos réus. É que ficou nítido que Ana Cláudia trazia as drogas para entrega ao seu companheiro e que ele, posteriormente, as distribuiria no interior de um estabelecimento prisional que conta com cerca de dois mil presos.

As palavras dos agentes penitenciários devem ser acatadas por merecerem crédito. De fato, são servidores públicos, concursados, nos quais o Estado deposita confiança para desempenho do mister. Seria verdadeira contradição o mesmo Estado, agora na função jurisdicional, afastar ou diminuir o valor das palavras dos agentes públicos que apuraram os fatos. Saliento que nada nos autos indica o desejo dos servidores de imputar condutas tão graves aos réus de maneira inverídica. Nesse sentido, exemplo da farta jurisprudência:

"As palavras dos agentes penitenciários e do chefe de segurança do presídio devem ser acatadas, pois são servidores públicos, nada indicando desejo de imputar condutas tão graves aos réus de maneira leviana. Nesse sentido, exemplo da farta

jurisprudência: E esses testemunhos, aliados às condições em que se deu a apreensão do entorpecente, não deixam dúvida quanto à intenção de praticar a traficância no interior do estabelecimento prisional. Não é, outrossim, de suspeitar-se da narrativa dos agentes penitenciários, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha.”. (Apelação TJSP nº 0004237-69.2012.8.26.0483 - Comarca: Presidente Venceslau - Juízo de Origem: 2ª Vara Judicial - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Criminal - Relator Ivan Sartori).

“APELAÇÃO CRIMINAL CORRUPÇÃO ATIVA OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA PENA VERSÕES CONTRAPOSTAS NADA A RETIRAR A CREDIBILIDADE DO RELATO DO AGENTE PENITENCIÁRIO NARRATIVA QUE SE SOBREPÕE À SIMPLÓRIA NEGATIVA DO DETENTO (...).” (TJSP, Apelação nº 0015216-47.2010.8.26.0229, 6ª Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Euvaldo Chaib, J. 11.09.2015).

“A palavra dos agentes penitenciários não pode ser descartada somente em razão da profissão exercida pelas testemunhas, sendo necessário, para que se coloque em dúvida tais depoimentos, a presença de indícios sérios e idôneos nesse sentido, o que não ocorreu no caso.” (Apelação TJSP nº 0000356-97.2015.8.26.0283, Julgado em 24/09/2018, 2ª Câmara, Relator: Sergio Mazina Martins, DJe. 03/10/2018).

“Vale ressaltar que os relatos dos agentes penitenciários envolvidos na apreensão das drogas são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu. A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis”. (Apelação nº 1501774-69.2018.8.26.0548 - 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. César Augusto Andrade de Castro - julgado em 04/12/2019).

João Vitor confessou que pediu para Ana Cláudia lhe trazer as drogas, alegando que pretendia consumir a maconha e vender o LSD dentro da unidade prisional. A acusada, por sua vez, também confessou que transportava as substâncias ilícitas em seu corpo para o interior do estabelecimento penal a pedido de seu companheiro. Nesse passo, o pleito defensivo de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas não merece acolhida vez que está divorciada do conjunto probatório dos autos. Destaco que o réu pode até ser mesmo usuário de drogas, mas tal fato não significa que se trate de mero usuário de drogas, pois as condições de usuário e traficante não são excludentes. O acusado confessou a traficância e disse que as drogas destinavam-se para o comércio e também para o seu uso, possivelmente o típico caso em que o uso e a traficância são desempenhados em paralelo, até para sustento do hábito.

Consigno, por oportuno, que é cediço que pode haver pressão ou até mesmo ameaças pelos sentenciados para que seus familiares entrem com drogas no interior dos presídios. A adesão ao pedido, porém, é opção do familiar. No caso em questão, a acusada preferiu aderir ao pedido do companheiro, levando a substância ilícita a ele, com nítido dolo de ingressar no presídio levando drogas que sabia que seria destinada ao comércio.

Destaco que a traficância foi confirmada em juízo pelas testemunhas de acusação, em especial pelo depoimento do diretor de segurança e disciplina da unidade prisional, que mencionou a existência de denúncia anônima sobre o tráfico de drogas praticado pelo acusado dentro do estabelecimento prisional, que foi confirmada pela apreensão de farta quantidade de entorpecentes com a visitante, bem como pela confissão dos réus, o que indica claramente o envolvimento de ambos no comércio espúrio.

Por oportuno, consigo que opera-se o crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica no caso em tela. A vistoria nas visitantes e em seus pertences, ainda que minuciosa, dificulta a entrada de entorpecentes na penitenciária, mas não a torna impossível.

Do contrário, não haveria tantos procedimentos de igual natureza no sistema prisional.

Além disso, o crime se consumou nas modalidades trazer consigo e ocultar, do que se extrai que antes mesmo da apreensão das drogas pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado, sendo desnecessário que a droga de fato ingressasse no presídio. Esse tem sido o entendimento das Câmaras de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos:

“Inicialmente, buscam os Apelantes suas absolvições, aduzindo se tratar de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio, isso porque a existência de scanner no estabelecimento prisional impediria, de qualquer forma, a consumação do crime. Para caracterização de crime impossível, é necessário não existirem meios de o agente conseguir chegar à consumação do crime, o que não ocorreu no caso dos autos. O fato do estabelecimento prisional possuir um scanner na revista, o que impediria o ingresso de materiais não permitidos, não é garantia de que JULIANE não conseguiria atingir seu intento”. (Apelação nº 1500429-58.2019 – 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Luis Antônio Cardoso – julgado em 03/12/2019).

“Ademais, a conduta é típica, ainda que o apelante não tivesse conseguido efetivamente tomar posse da droga dentro do presídio. Desta forma, sendo o tráfico de drogas um tipo penal de conteúdo misto alternativo, qualquer das condutas descritas em seu preceito primário tipifica o delito”. (Apelação nº 1500321-58.2018.8.26.0283 – 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Tozola Neto – julgado em 12/12/2019).

“Ademais, não se exige prova de que alguma pessoa tenha efetivamente adquirido entorpecente do acusado, eis que, para a caracterização do tráfico, não é necessário que o indivíduo esteja praticando algum ato de mercancia, bastando que exista apenas uma das condutas previstas pelo art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla. Ou seja, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, adquirir e remeter entorpecentes para consumo de terceiros, o que no caso restou comprovado”. (Apelação nº 1501687-79.2018.8.26.0624 – 11ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Guilherme G. Strenger – julgado em 04/09/2019).

“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS, Ap. 697.020.717, 1ª Câ., j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Assim, o crime já estava consumado quando a droga foi encontrada pelos agentes penitenciários, independentemente da acusada lograr transmitir o entorpecente ao seu companheiro.

Nesse passo, de rigor a condenação dos acusados para o crime de tráfico de drogas, visto que, embora João Vitor não tenha podido praticar a conduta de entregar a droga a terceiros como pretendia, solicitou que sua companheira lhe trouxesse o entorpecente, com ela, pois, praticou o delito. E, sem sombra de dúvidas, este foi o panorama em que se deram os fatos: buscou o acusado o auxílio de sua companheira para fazer com que a droga pudesse ingressar no interior do presídio e, assim, distribuí-la aos demais reeducandos.

Portanto, demonstradas a autoria e a materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isentem os agentes de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP.

No que concerne ao acusado João Vitor de Almeida:

Quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, em atenção ao disposto nos artigos 42 da Lei de drogas e 59 do Código Penal, observo que o acusado responde por três delitos de roubo (fls.

145/148), mas ressalto que a jurisprudência da C. Terceira Seção do STJ não admite sequer que condenações pretéritas sejam desvaloradas negativamente a título de personalidade e de conduta social (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO

SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019), de forma que também é inadmissível neste ponto a consideração de processos em andamento. A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime de tráfico de drogas e os motivos e as consequências não ultrapassaram a gravidade natural do delito em tela. Ressalto que, em respeito à vedação ao bis in idem, a quantidade e natureza da droga não será considerada neste primeira fase, pois servirá como fundamento para afastamento do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparo. A consideração da quantidade e natureza dos entorpecentes na 1ª etapa, para elevar a pena-base, e na 3ª fase, para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, configura vedado bis in idem. Afastado o incremento aplicado sobre a basilar. Relevante quantidade de drogas variadas que impede a redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da referida lei. Regime inicial semiaberto que melhor se amolda à espécie e às finalidades da sanção penal. Inviável por disposição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1504022-27.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

Assim, fixo a pena base privativa de liberdade no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, ausentes as agravantes. Presente a atenuante da confissão, a qual não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, por conta do disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (delito cometido nas dependências de estabelecimento prisional), aumento a pena em 1/6 e, não havendo causas de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva.

Deixo de aplicar em favor do réu o redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, uma vez que restou demonstrada a dedicação a atividades criminosas. Isso porque, apesar da primariedade, o acusado ostenta três condenações por delito de roubo (fls. 145/148) e solicitou a sua companheira que trouxesse considerável quantidade de drogas - 98 g (noventa e oito gramas) de maconha e 100 (cem) unidades da droga conhecida como "LSD" - para venda no interior de um presídio.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada e à natureza e à quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/2006. Tendo em vista o montante de pena aplicado, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelo mesmo motivo, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

No que concerne à acusada Ana Cláudia Pereira Vieira:

Quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, em atenção ao disposto nos artigos 42 da Lei de drogas e 59 do Código Penal, observo que a acusada é primária (fls. 23/25). A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime de tráfico de drogas e os motivos e as consequências não ultrapassaram a gravidade natural do delito em tela.

Ressalto que, em respeito à vedação ao bis in idem, a quantidade e natureza da droga não será considerada nesta primeira fase, pois servirá como fundamento para a dosagem do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparo. A consideração da quantidade e natureza dos entorpecentes na 1ª etapa, para elevar a pena-base, e na 3ª fase, para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, configura vedado bis in idem. Afastado o incremento aplicado sobre a basilar. Relevante quantidade de drogas variadas que impede a redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da referida lei. Regime inicial semiaberto que melhor se amolda à espécie e às finalidades da sanção penal. Inviável por disposição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1504022-27.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

Assim, fixo a pena base privativa de liberdade no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, ausentes as agravantes. Presente a atenuante da confissão, a qual não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, por conta do disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (delito cometido nas dependências de estabelecimento prisional), aumento a pena em 1/6 e, não havendo causas de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, tendo em vista que a quantidade de drogas, por si só, não impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 (a propósito: AgRg no AREsp 1955819/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022), impõe-se o reconhecimento do privilégio. De todo modo, a acusada portava considerável quantidade de droga - 98 g (noventa e oito gramas) de maconha e 100 (cem) unidades da substância conhecida como "LSD" (droga de natureza sintética) para tentar ingressar no interior de um estabelecimento prisional, de forma que o redutor será fixado no patamar de 1/3. Assim, fixo a pena definitiva em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 389 dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada e à natureza e à quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/2006. Como assentado pelo Tribunal Pleno do Colendo STF, "... o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa ..." (STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016)

Desse modo, reconhecido o privilégio, diante da quantidade da pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como por uma pena de multa, calculada no mínimo legal.

Os acusados responderam o processo em liberdade e, não se fazendo presentes os

requisitos para a decretação da prisão preventiva, mantenho o benefício em respeito ao princípio da contemporaneidade e autorizo que recorram deste pronunciamento em liberdade.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PEDIDO o pedido da presente ação penal, para o fim de:

a) condenar JOÃO VITOR DE ALMEIDA, qualificado nos autos, pela prática do crime consubstanciado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no mínimo legal.

b) condenar ANA CLÁUDIA PEREIRA VIEIRA, qualificada nos autos, pela prática do crime consubstanciado no artigo 33, caput e § 4º c/c artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial semiaberto e 389 dias-multa, fixados no mínimo legal e substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e por pena de multa.

c) absolver os réus JOÃO VITOR DE ALMEIDA, qualificado nos autos, e ANA CLÁUDIA PEREIRA VIEIRA, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, , nos termos do art. 386, VII do CPP

Tendo em vista que não existem dúvidas sobre a natureza e quantidade das substâncias apreendidas, tampouco acerca da regularidade dos laudos toxicológicos, determino a destruição por incineração das drogas apreendidas, preservando-se amostras mínimas necessárias de cada substância para eventual contraprova (art.58, §1º c.c art.32, § 1º da Lei nº 11.343/06).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em prol do ilustre Advogado que atuou no feito em função do convênio da assistência judiciária.

Após o trânsito em julgado: 1- comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 2- lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, inc. II, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3- oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); 4 - expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor nomeado para atuar no feito; 5 - intímem-se os condenados para efetuarem o pagamento da multa imposta na sentença; 6- formem-se os processos de execução para cumprimento das penas aplicadas, encaminhando-se o ao Juízo competente para tanto e 7- arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Casa Branca, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA